

1530545-62.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito à garantia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530545-62.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530545-62.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2280452/2019 - 26º D.P. SACOMA, 4688826 - 26º D.P. SACOMA, 876/19/308 - 26º D.P. SACOMA, 2280452 - 26º D.P. SACOMA, 876/19/308 - 26º D.P. SACOMA, 2280452 - 26º D.P. SACOMA, 876/19/308 - 26º D.P. SACOMA, 2280452 - 26º D.P. SACOMA, 876/19/308 - 26º D.P. SACOMA, 2280452 - 26º D.P. SACOMA, 876/19/308 - 26º D.P. SACOMA, 2280452 - 26º D.P. SACOMA, 876/19/308 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

LUCAS REZENDE VIANA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, porque, no dia 24 de abril de 2019, por volta das 07h40min, na Rua Ulisses Cruz, nº 1.148, Tatuapé, juntamente com outros três indivíduos não identificados, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade da vítima R.S.A, 496 (quatrocentos e noventa e seis) pacotes de cigarro, de marcas variadas, avaliados globalmente em R\$ 42.444,13 (quarenta e dois mil

quatrocentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), conforme boletim de ocorrência de fls. 04/05, pertencentes à empresa Phillips Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Segundo a exordial, LUCAS e três indivíduos não identificados, previamente ajustados, deliberaram pela prática de roubo a cargas de cigarro. Assim é que, na data dos fatos, após realizar uma entrega, R.S.A, motorista da transportadora de cigarros da empresa vítima, foi abordada por LUCAS quando entrava em seu veículo, um Fiat/Fiorino de placas FZX 2723. Demonstrando ter conhecimento sobre o sistema de rastreamento do veículo, o denunciado simulou estar armado e, mediante grave ameaça, exigiu que R.S.A. passasse para o banco do passageiro e baixasse o vidro para que ele entrasse pela janela sem que o alarme fosse acionado. Na sequência, LUCAS assumiu a direção do Fiat/Fiorino e ordenou que a vítima permanecesse no veículo, de cabeça baixa, restringido a sua liberdade. Após conduzi-lo por um tempo, o denunciado estacionou o veículo. Em seguida, uma pick-up preta parou logo atrás, de onde dois indivíduos desceram e começaram a descarregar a carga de cigarros do veículo da vítima. Outro indivíduo ficou no banco do motorista da pick-up, sendo que R.S.A. permaneceu sob a vigilância de LUCAS. Depois que efetuaram a transferência da carga para a pick-up, os quatro roubadores se evadiram do local. Posteriormente, R.S.A. compareceu à unidade policial, ocasião em que, ao compulsar o acervo fotográfico, reconheceu prontamente a fotografia de LUCAS (fls.10 e auto de reconhecimento fotográfico positivo a fls. 15/16).

Na denúncia foram arroladas as testemunhas MARCO ANTONIO MENDES CARDOZO e VALTER DE OLIVEIRA e vítima: R.S. A.

Recebida a denúncia em 06/08/2021 às fls. 122/123.

O réu foi citado (fls. 143/144).

Resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública a fls. 147/148. Nessa oportunidade, foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia, foi designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 150/151).

Certidões criminais do acusado juntada a fls. 113/115, sendo o réu reincidente com maus antecedentes.

Em audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, bem como o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa pleiteou a absolvição do réu por falta de provas.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Roubo.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.(STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 09/11/2015, Tema 916 dos Recursos Repetitivos.)

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5), termo de declarações e interrogatório (fls. 6), e, sobretudo, pela prova oral colhida.

O mesmo não é possível dizer da autoria.

Na delegacia, o réu LUCAS REZENDE VIANA não foi interrogado.

Em juízo, o réu LUCAS REZENDE VIANA negou os fatos dizendo que não tem nada a ver

com os roubos que estão jogando. Em 2019 emprestou seu carro Palio para o seu sogro, então sua mãe ligou dizendo que ele tinha sido pego com uma carga de cigarro. No seu carro estava sua habilitação. Foi na delegacia, falaram que o seu sogro não foi preso em flagrante. Lá tiraram sua foto e se dispôs a ir no local. Desde então toda vez que tem um roubo na região estão colocando em cima do depoente.

A versão apresentada pelo réu não foi afastada pelas demais provas acostadas aos autos.

A vítima R. S. A. disse que não reconhece o réu em juízo. Disse que foi ao mercado fazer uma entrega e quando retornou foi abordada por um rapaz branco, alto, e solicitou que pulasse para o banco do passageiro e pegou a direção. Saiu com carro por ruas que não conhece, parou o carro, pediu para abrir o baú. Viu que tinha um carro alto seguindo como uma pickup e mais dois rapazes pelas vozes e fizeram o transbordo da carga. Depois o levaram para ruas mais próximas e o deixaram com o carro. A pessoa que a abordou estava de boné, não conseguiu ver seu rosto, já mandou abaixar a cabeça. Os outros estavam em um carro atrás. Dói na delegacia, fez o boletim de ocorrência, encontrou dois policiais e passou a ocorrência. Não fez reconhecimento na delegacia. Um tempo depois fez um reconhecimento fotográfico. Reconheceu o rapaz pela tatuagem na mão, uma rosa que cobria toda a mão. Ele era alto e branco. Não se lembra da foto que foi mostrada, se era de corpo inteiro. O rapaz numero 1 lembra o rapaz, mas não pode dar certeza. Ele mostrou parte da arma levantando a blusa mas não pode ver em punho. Foi mostrado um álbum e acha que a foto não era colorida.

A testemunha MARCO ANTONIO MENDES CARDOZO afirmou que estavam com investigação e quadrilha especializada em roubo de carga de cigarro em contato com o setor de rastreamento e monitoramento e ele foi passando os roubos. Um dos roubos a vítima avistou o emplacamento da motocicleta usada no roubo que era sempre usado uma moto e um carro. Passada a placa, levantaram a pessoa de nome Lucas que seria o proprietário da moto, pesquisaram o antecedente ele tinha passagem por roubo de carga de cigarro na região. Todos os roubos a mercadoria estava sendo levada para a região da residência do Lucas. Conseguiram levantar a qualificação e a foto do réu, chamaram as vítimas e 5 delas reconheceram o réu sem dúvidas. Mostraram várias fotos de elementos que roubavam na região. Fizeram diligências na residência dele mas não o encontraram. Saiu da delegacia antes de sair o mandado de busca e apreensão. Teve contato com as vítimas que compareceram na delegacia. Sabe que em um dos casos o réu sabia os dados da vítima, onde ela morava e a ameaçou. Apresentavam as fotos uma do lado da outra. A foto era do busto para cima e colorida. Não se recorda das descrições dadas pelas vítimas. A empresa indicou os funcionários que foram vítimas de roubo e eles foram fazer o reconhecimento. Eles roubavam em SP todo mas a empresa fica em Barueri.

A testemunha VALTER DE OLIVEIRA afirmou que estavam investigando uma quadrilha de roubo de cigarros e estava monitorando pela empresa e passaram que uma das vítimas tinha visualizado uma moto e passaram a emplacação e em pesquisa chegaram no réu Lucas e puxando a sua foto e qualificação ele tinha passagem por roubo de cigarro. Fizeram contato com a empresa, foi feito reconhecimento fotográfico com várias vítimas e 5 delas reconheceram o réu. Foram mostradas várias fotos, não lembra se a foto era colorida. Não teve contato com o réu.

A prova do feito pe baseada no reconhecimento fotográfico extrajudicial, contudo a vítima não reconheceu o réu em juízo, dizendo que não foi possível ver o rosto do assaltante, afirmando que o reconhecimento na delegacia se deu pela tatuagem da mão do acusado que seria uma rosa que cobriria a mão inteira, entretanto a foto que consta dos autos usada para o reconhecimento (fl. 16) é apenas do rosto do réu, não sendo possível ver sua mão.

Some-se a isso em que juízo, a pedido dessa magistrada, o réu mostrou suas mãos e não consta qualquer tatuagem de rosa, tendo apenas tatuagens nos braços, e letras nos dedos da mão direita (DEUS) e um crucifixo bem pequeno, que de forma alguma poderia ser confundido com uma rosa que cobrisse a mão, assim, se o reconhecimento seria apenas pela tatuagem, o réu teria que ser excluído como suspeito, pois não leva qualquer tatuagem que se assemelhe a uma rosa nas mãos.

Assim, ainda que os policiais tenham dito que houve o reconhecimento, além dele não ser confirmado em juízo, a vítima apresentou versão completamente diversa da dada em sede inquisitória.

No caso em tela, todo o delito se baseia tão somente no reconhecimento fotográfico feito pela vítima em sede inquisitória que não foi confirmado em juízo, não havendo assim uma prova sequer produzida em sede de contraditório que levasse à responsabilização do réu.

Assim, o desrespeito às normas legais no reconhecimento fotográfico, somado a fragilidade de provas, em especial o não reconhecimento inicial pelo ofendido em juízo, e as circunstâncias fáticas não é possível um decreto condenatório.

Nesse sentido foi o julgado recente do STJ do qual transcrevo algumas partes: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (HABEAS CORPUS Nº 712781 - RJ (2021/0397952-8) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ)

Como bem ponderou o ministro neste julgado:

O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto. 8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc

Nesse sentido também é o entendimento doutrinário:

No que refere ao reconhecimento de pessoas, a maleabilidade e a função de aprender geram um efeito não desprezível: quando um rosto é apresentado a uma vítima e esta o reconhece como sendo autor do crime, seu cérebro "aprende" que o rosto reconhecido é o rosto visto no local do crime. Assim, todo reconhecimento é impactado diretamente por reconhecimentos anteriores, sendo o primeiro reconhecimento a oportunidade em que se pode ter acesso à memória mais livre de contaminações possível. Ou seja, um reconhecimento feito em Juízo utilizando

métodos adequados não tem a capacidade de remediar os efeitos de um primeiro reconhecimento irregularmente produzido. Sendo o primeiro reconhecimento primordial para a identificação de autoria, é preciso zelar pela sua adequada realização.

(MATIDA, Janaina; CECCONELLO, William. Outra vez sobre o reconhecimento fotográfico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-out-01/limite-penal-outra-vez-reconhecimento-fotografico>. Acesso em: julho. 2022)

Fica claro assim que o reconhecimento inicial realizado afeta todos os subsequentes, de modo a reforçar ainda mais a importância de que ele seja feito mediante um procedimento que assegure a lisura do ato, em especial quando que se tem a compreensão de que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

Ademais, analisando o conjunto probatório, conclui-se que não há uma única prova, produzida em juízo, no sentido de que o acusado tenha sido um dos autores do grave crime cometido.

Tal circunstância, desacompanhada de provas judicializadas da autoria, não permite que se chegue a um decreto condenatório.

Tal proteção ao contraditório é de tanta importância que na reforma legislativa de 2008, foi incluída expressamente essa previsão no artigo 155 do Código de Processo Penal que diz: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP.

OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito à garantia constitucional do devido processo legal, a legitimidade do poder-dever do Estado aplicar a sanção prevista em lei ao acusado da prática de determinada infração penal deve ser exercida por meio da ação penal, no seio da qual ser-lhe-á assegurada a ampla defesa e o contraditório. 2. Visando afastar eventuais arbitrariedades, a doutrina e a jurisprudência pátrias já repudiavam a condenação baseada exclusivamente em elementos de prova colhidos no inquérito policial. 3. Tal vedação foi abarcada pelo legislador ordinário com a alteração da redação do artigo 155 do Código de Processo Penal, por meio da Lei n. 11.690/2008, o qual prevê a proibição da condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 4. Constatado que o Tribunal de origem utilizou-se unicamente de elementos informativos colhidos no inquérito policial para embasar o édito condenatório em desfavor do paciente, imperioso o reconhecimento da ofensa ao aludido dispositivo do Estatuto Processual Penal, já em vigor na data da prolação do acórdão objurgado, bem como à garantia constitucional ao devido processo legal. 5. Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório apenas com relação ao paciente, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, com a determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 123295 MT 2008/0272631-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2009)

A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela polícia judiciária na fase preliminar da persecução penal e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade de da instrução criminal contraditória.

A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos tribunais, cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo.

Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia.

Em suma, da prova oral produzida em juízo não se extraem elementos suficientes para um decreto condenatório.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubidosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso.

Em razão disso, já se decidiu: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu LUCAS REZENDE VIANA, qualificado nos autos, das sanções 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

Custas não são devidas.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA